

1501129-15.2020.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501129-15.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501129-15.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 20h10min, na Rua Santo Antônio, nº 495, Vila Dona Leonor, na cidade de Barbosa, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) porções de "cocaína" na forma de crack, com peso líquido de 5,47g (cinco gramas e quarenta e sete centigramas), e 05 cinco porções da mesma substância, com peso líquido de 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata-se na peça acusatória que, naquele dia, policiais militares efetuavam patrulhamento nas proximidades do local dos fatos, momento em que avistaram CARLOS defronte à residência dele. Nessas circunstâncias e por haver notícia de que o local era ponto de venda de drogas, CARLOS foi abordado pelos policiais.

Em busca pessoal, foram localizadas nos bolsos da calça duas sacolas, sendo que em uma havia 05 (cinco) porções de cocaína, em outra 28 (vinte e oito) porções de crack e R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro, tendo o réu confessado aos policiais.

Os agentes públicos adentraram na residência de CARLOS a fim de pegar documentos pessoais, momento em que encontraram, sobre a mesa, um rolo de papel alumínio e uma tesoura, sendo que havia retalhos de alumínio já cortados.

O réu foi citado (fl. 169) e apresentou defesa preliminar (fls. 175/177), tendo a denúncia sido recebida em 6.12.2021 (fls. 182/187). Durante a instrução, o réu foi interrogado (fl. 230), sendo ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 228/229).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, enfatizando seus maus antecedentes e reincidência (fls. 226/227).

A Defesa, por sua vez, postulou a desclassificação para posse de droga para uso pessoal ou então aplicação de pena mínima, com substituição por PRD (fls. 231/234).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) auto de exibição e apreensão (fls. 8/9); iii) boletim de ocorrência (fls. 5/7); iv) laudo definitivo para cocaína (fls. 118/120 e 121/123); v) laudo pericial na tesoura apreendida na residência (fls. 124/129).

Resta saber se a autoria foi evidenciada pela prova oral colhida nos autos.

A testemunha comum PM Elvis Fernandes de Jesus disse que participou da prisão do réu sendo que, na casa dele, já havia denúncia de tráfico vinda de usuários. Abordaram-no outras vezes, mas nada foi achado até então. No dia dos fatos, porém, no portão da casa dele, encontraram-no com 28 pedras de crack – crack num saquinho e cocaína em outro saquinho. Ele confirmou que traficava e que o fazia porque tinha diabetes alta e precisava sobreviver, até porque não conseguia benefício do INSS nem trabalho. Na casa, encontraram papel alumínio em cima do balcão, porém não havia droga por perto.

A testemunha comum PM Cleber dos Santos da Mata confirmou as informações de seu colega, dizendo que a abordagem ocorreu dadas as denúncias de tráfico no local por ele. As porções estavam com ele, no bolso e, no outro, R\$ 62,00 em notas diversas. Entraram na residência para pegarem o RG dele, onde encontraram papel laminado, papel cortado e tesoura. O réu reconheceu que estava traficando em razão do desemprego e não ter conseguido se aposentar.

Em seu interrogatório, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE disse que estava dentro de casa e escutou barulho no portão, quando viu que os PMS estavam com arma na mão e mandaram por a mão na cabeça. Estava com umas drogas no bolso: acha que tinha umas 4/5 porções de pó. Não tinha dinheiro com ele. Morava no sítio comunitário, onde tocava roça e criava porcos, junto com outras 5 pessoas, porém ficou doente e precisou ir à cidade. Como não é aposentado, precisou pegar a droga para vender para sobreviver, pois, em razão da doença, não podia trabalhar e nem conseguiu o benefício. Dentro da casa, havia o rolo de papel alumínio. Vendia a porção de cocaína a R\$ 10,00. Nunca deu trabalho para a Polícia e não teve problema pessoal com esses policiais. Não chegou a vender droga dias antes, mas a droga que estava com ele era, parte, para venda, pois precisava de dinheiro.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

No tocante à lisura dos depoimentos dos policiais, impende seja destacado que os testemunhos dos policiais revestem-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos. Aliás, nesse sentido o entendimento pretoriano (RJTJESP 90/496 e 135/493).

De qualquer modo, o réu foi enfático em dizer que nada tem contra os policiais que atuaram no caso e que estes não o perseguiram. Confessou a traficância, dizendo que parte da droga encontrada de fato era para venda, já que, incapaz, não conseguia trabalho (pandemia) nem benefício do INSS. Apenas ressaltou que não havia aquela quantidade de droga com ele, mas apenas 5 papérolas, o que, de uma forma ou de outra, não descaracteriza a traficância.

Não bastasse a descoberta de droga por ocasião da revista pessoal, lograram êxito em encontrar dinheiro com ele e, dentro de sua casa, papel alumínio e tesoura, conforme laudos de fls. 113/117, que aponta que, parte do papel, já estava picotado, típico de venda.

Assim, a traficância restou configurada.

No mais, não vislumbro causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual a sua responsabilidade penal é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são desfavoráveis ao réu, uma vez que ostenta maus antecedentes (fls. 206/207 - condenação definitiva por crime de arma de fogo 0037713-96.2001.8.26.0576, com TJ para a Defesa em 9.9.2005; fls. 208/209: condenação definitiva por tráfico 0047979-40.2004.8.26.0576, com TJ para a Defesa em 3.10.2011), pelo que a pena inicial deve ser fixada acima de seu patamar mínimo, a saber, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no menor valor (aumento de 1/6).

Não há como considerar tais condenações como reincidência, dado o período depurador, pelo que computadas apenas na 1ª fase de dosimetria da pena.

Não incide a agravante da reincidência (fls. 205 - condenação não definitiva por tráfico, nos autos n. 1501504-16.2020.8.26.0438), justamente pela ausência de trânsito em julgado e porque, de qualquer forma, o fato objeto do tal feito é posterior (15.10.2020) ao presente - pelo que mantida a pena no patamar anterior. Contudo, o aumento da 1ª fase resta neutralizado pela confissão espontânea, pelo que volta a pena ao seu patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no menor valor

Sem causas de aumento. Quanto à causa de diminuição, não há como deixar de incidir pois, pois os antecedentes do réu são antigos, a quantidade de droga é pequena e, quanto à condenação por tráfico é recente (agosto de 2021) e não definitiva, de modo que não há prova de que ele se dedica a atividades criminosas ou integrar organização da mesma natureza.

Porém, ante o tal quadro fático narrado, aplico-lhe a diminuição mínima de 1/3, perfazendo, assim, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser

considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá,

portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráfico privilegiado, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CARLOS ALBERTO DE ANDRADE como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, devendo cumprir a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333

(trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

A considerar a natureza da pena aplicada, permito-lhe recorrer em liberdade, o que, de qualquer forma, fica prejudicado enquanto o réu estiver preso por outro processo.

Condeno ainda o réu às custas e despesas do processo, cujo pagamento fica dispensado caso beneficiário da AJG.

Transitado em julgado, tenha seu nome lançado no rol dos culpados (CF, art. 5º , inciso LVII).

Honorários advocatícios nos termos do Convênio OAB/DP.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi. Quanto aos demais objetos e numerário apreendidos, decreto seu perdimento, considerando a inexistência de prova acerca de sua origem lícita.

P.R.I.C.

Penápolis, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA